

1500356-66.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Simone Rodrigues Valle

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... da Lei 11.343/06 o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 14/16, auto de exibição e apreensão às fls. 12, pelo laudo de constatação preliminar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista - SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500356-66.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500356-66.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI RENATO ZAMANA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Simone Rodrigues Valle

Vistos.

GIOVANI RENATO ZAMANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 27 de março de 2022, por volta das 19h30min, na altura do numeral 280, da Rua São Marcos, Cruzeiro, nesta cidade e Comarca de Bragança Paulista, o acusado, agindo com unidade de desígnios e propósitos com o adolescente, JEAN VINICIUS DIAS DE SIQUEIRA, trazia consigo, para fins de tráfico, 16 (dezesseis) porções de maconha, e 01 (uma) porção de maconha em farelo, pesando cerca de 52g (cinquenta e dois gramas), 01 (uma) porção média de maconha, e 05 (cinco) porções pequenas de maconha, pesando cerca de 58g (cinquenta e oito gramas), além de um aparelho celular e a quantia de R\$ 21,50 (vinte e um reais e cinquenta centavos).

O acusado foi devidamente notificado (fls. 91/92) e apresentou resposta à acusação às fls. 110/111.

Após, a denúncia foi recebida, em 03 e junho de 2022, às fls. 118/121.

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado (fls. 163/166).

Encerrada a instrução, o Ministério Público reiterou a juntada das certidões da Vara da Infância e Juventude Local em nome do acusado.

Com a juntada, o Ministério Público se manifestou em memoriais, oportunidade em que requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Manifestou-se sobre a dosimetria da pena (fls. 193/199).

A Defesa, por sua vez, se manifestou às fls. 218/242, requerendo a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do CPP ou a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, requereu a condenação em seu mínimo legal, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se totalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 14/16, auto de exibição e apreensão às fls. 12, pelo laudo de constatação preliminar (fls. 13) e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 81/86), que apontou resultado positivo para tetrahydrocannabinol (THC) nas substâncias entorpecentes apreendidas na ocasião, bem como pela prova oral produzida nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, também, restou comprovada.

Na fase policial, o acusado negou a prática da traficância, dizendo ser usuário e que a droga é para seu consumo. Quanto ao adolescente, disse que são amigos (fls. 22/23).

Em juízo, o réu negou os fatos. Disse que é usuário, comprou a droga no bairro Matadouro para seu uso e, no caminho, encontrou o adolescente Jean e parou para cumprimentá-lo quando foram abordados. Afirmou que a droga foi encontrada com ele e que não sabe se havia droga com Jean, Negou ter lhe passado uma sacola. Relatou que pagou R\$ 100,00 pela droga que estava embalada, sendo 16 porções, e adquiriu o farelo por mais R\$ 50,00. Indagado acerca de onde o acusado residia na época dos fatos, disse que na casa de sua mãe, mas que também ficava na casa de sua irmã. Disse que usa drogas desde os 13 anos, que nunca foi internado e que sua família sabe. Afirmou que não confessou a traficância informalmente aos policiais.

O policial militar, Douglas Rodrigues Gonçalves, disse que em patrulhamento com seu parceiro pelo local dos fatos, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, depararam-se com o acusado e o adolescente e, assim que o acusado avistou os policiais, passou uma sacola para o menor. Feita a abordagem, com o acusado foi encontrado R\$ 21,50 e um celular e com o menor foram encontradas 5 buchas de maconha em seu bolso, um celular e um pedaço de maconha. Na sacola que o réu havia passado para o menor foram encontradas mais 16 buchas de maconha e farelo de maconha. Indagado, o réu disse que faria a venda na Praça do Cruzeiro. Esclareceu que o que ensejou a abordagem foi justamente a passagem da sacola do acusado para o menor.

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial militar, Lucas Lozardo Cavalcante, que acrescentou que visualizaram o acusado e o adolescente caminhando e esclareceu que assim que ambos avistaram a viatura, o acusado entregou uma sacola de forma dissimulada para o adolescente, o que motivou a abordagem. Relatou que tanto o acusado como o adolescente confirmaram a traficância e disseram que haviam comprado a droga e a revenderiam na Praça do Cruzeiro. Afirmou que o bairro é conhecido como ponto de venda de drogas e que as drogas estavam embaladas prontas para a venda. Havia farelo de maconha, que os traficantes costumam picar para embalar e vender posteriormente.

Assim, ao término da instrução processual, verifico que a autoria é certa para o acusado.

Apesar de o réu ter negado a prática da traficância, afirmando que a droga encontrada com ele era para seu uso, tal versão restou totalmente isolada do

conjunto probatório.

É certo que os policiais militares foram uníssomos ao relatarem que em patrulhamento pelo local, já conhecido pela prática do tráfico, depararam-se com o acusado, na companhia do adolescente, e que, ao visualizar a viatura, entregou uma sacola para o menor, o que motivou a abordagem.

Feita a abordagem, foi encontrada uma quantia em dinheiro com o acusado, bem como drogas no interior da sacola entregue pelo réu, além de drogas com o adolescente. Quanto a validade dos depoimentos dos policiais militares, deve ser dado expressivo valor aos relatos apresentados pelas testemunhas ouvidas, pois não ficou demonstrado qualquer indício de sentimento pessoal de parte daqueles que efetivaram a prisão do acusado em prejudicá-lo, sem qualquer elemento concreto nesse sentido. Esse é o entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.).

Assim "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Desse modo, restou comprovada a propriedade da droga por parte do réu, restando analisar a sua finalidade e outra conclusão não se chega senão a finalidade mercantil.

Com efeito, as circunstâncias da prisão, durante patrulhamento de rotina, da quantidade de droga encontrada, significativa para quem se diz mero usuário, além do dinheiro apreendido sem comprovação de origem lícita, em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, comprovam a sua finalidade mercantil.

Destaque-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas, ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

No mais, a alegação da defesa de que o acusado seria usuário não prospera.

Como já dito, a quantidade de droga é significativa para quem se diz mero usuário, não tendo o réu ainda comprovado ter condições financeiras de comprar referida droga para uso próprio.

Ademais, a mera alegação de que é usuário não tem o condão de permitir a desclassificação, conforme pretendido, pois como é sabido, normalmente encontram-se em uma mesma pessoa as figuras de usuário e traficante, sem que com isso saia ileso do crime de maior gravidade.

E todas as circunstâncias do caso em concreto, como já dito acima, comprovam a sua finalidade mercantil, não havendo que se falar em insuficiência de provas, de modo que a versão do réu resta isolada nos autos.

Por fim, fica reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da

Lei 11.343/06, já que restou comprovado a prática do crime com o envolvimento do adolescente Jean Vinicius Dias de Siqueira, conforme processo nº 1501757-80.2022.8.26.0099, que tramitou perante a Vara da Infância e Juventude para apuração do ato infracional.

Resolvido o mérito, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena não verifico circunstâncias judiciais que justifiquem a elevação da pena acima do mínimo legal, motivo pelo qual fixo a pena em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, verifico que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos e, assim, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, contudo sem reflexos na pena base, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/6 em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual fixo a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa no valor unitário mínimo legal, para todos os acusados.

Ainda, na terceira fase, verifico como recomendável seja aplicada a causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, principalmente porque essa causa de diminuição da pena subsuma-se à situação do acusado em questão (primário e não se vê a existência de antecedentes efetivos para justificar o impedimento dessa benesse, sem, também, qualquer demonstração de que se dedica à atividade criminosa ou integre organização criminosa), motivo pelo qual ela faz jus à redução de 2/3. Assim, estabeleço a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além de 194 dias-multa no valor unitário mínimo legal, tornando-a definitiva por não encontrar nenhuma outra circunstância modificadora aplicável. Em que pese a manifestação ministerial, entendo que a existência de antecedentes infracionais não tem o condão de impedir a aplicação do referido benefício.

Com efeito, o tema 1139 do STJ fixou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

Com muito mais razão então para se afastar os antecedentes da infância, quando o acusado era inimputável.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, anteriormente, ao tratar de casos envolvendo o tráfico de entorpecentes, sempre entendi, em atenção ao disposto no art. 5º, XLIII, da CF, a integral aplicação dos rigores da Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), a qual determina a imposição do regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 11.464/07), e da Lei nº 11.343/06, que veda a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, caput).

No entanto, ressalvada minha convicção pessoal, é necessário levar em consideração que, no âmbito dos Tribunais Superiores, em relação ao tráfico privilegiado, a Jurisprudência se consolidou para diferenciá-lo do tráfico em sua forma fundamental, tratando-o como delito não assemelhado a hediondo, sempre que preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Nessa ordem de ideias, o Plenário do E. STF, ao julgar o HC nº 118.533/MS, em 23/06/2016, decidiu que: "O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos". Em vista deste precedente, a 3ª Seção do C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, por unanimidade acolheu a tese vitoriosa no STF, revisando o entendimento até então firmado com o enunciado nº 512 daquela Corte, atualmente cancelado (Pet nº 11.796/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016).

Importante destacar, em tempo, as decisões do E. STF que em caráter incidental declararam inconstitucionais, por afrontarem a individualização da pena, tanto a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (HC nº 111.840/ES, j. 27/06/2012), quanto a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos da Lei de Drogas (HC nº 97.256/RS, j. 01/09/2010), com a consequente promulgação da Resolução nº 5 de 2012 pelo Senado Federal, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em

penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Embora proferidas em processos individuais, sem eficácia vinculante, essas decisões da Corte Suprema devem ser observadas, em nome da segurança jurídica e na busca da uniformidade na resolução de conflitos.

Sob essas premissas, passo a analisar o caso dos autos, tendo como objetivo o apenamento proporcional às condições pessoais do infrator e das circunstâncias específicas do comércio ilícito por ele desenvolvido, afastada a hediondez do delito e suas consequências.

O presente caso, enfim, versa sobre a apreensão de 16 porções de maconha e porção de farelo de maconha, relacionadas ao acusado, pesando aproximadamente 52 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12, na posse de indivíduo primário, sem provas de conexão com as organizações criminosas ou traficância habitual.

Consequentemente, revendo posicionamento anterior e cedendo à orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, fixo o regime inicial ABERTO para a execução da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 33, § 2º, "c", do CP. Ainda, porque presentes os requisitos correlatos, em atenção ao quantum de pena e à primariedade do réu, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44, § 2º, parte final, do CP.

A primeira consistirá na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, indicando o Juízo das Execuções tanto o destinatário como a espécie de serviço a ser prestado pelo tempo da pena substituída; a segunda em prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos na época do fato em favor de entidade pública ou privada, com destinação social, também a ser designada pelo Juízo das Execuções. Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra GIOVANI RENATO ZAMANA, para, com base no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, e c.c. o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, CONDENÁ-LO à pena 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 194 dias-multa no valor unitário mínimo legal, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade nos termos acima deliberados.

Tendo em vista a natureza da pena, poderá o réu recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de GIOVANI RENATO ZAMANA .

Comprovado que o dinheiro apreendido era produto do narcotráfico, decreto seu perdimento em favor da União (fls. 55).

Custas na forma da lei. Defiro a gratuidade processual. Anote-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Bragança Paulista, 31 de agosto de 2022.

Simone Rodrigues Valle

Juíza Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA